

<제4편 소송의 종료.제9장 당사자 행위에 의한 종료.제1절 소의 취하와 재소금지>

I. 소의 취하

1. 서설

(1) 의의

- 소의 취하란 원고가 제기한 소의 전체 또는 일부를 철회하여 소송계속을 소멸시키는 소송법상 의사표시를 의미한다. 이는 소송의 주도권이 원고에게 있다는 처분권주의의 발현으로, 원고는 판결이 확정될 때까지 소를 취하함으로써 소송절차를 종료시킬 수 있다.

(2) 구별개념

- 소의 취하는 소송물인 권리 자체를 부정하는 청구의 포기과 구별된다. 청구의 포기는 본안에 대한 패소 판결과 같은 효력을 가져 기판력이 발생하지만, 소의 취하는 소송절차만을 무효로 돌리는 것이므로 원칙적으로 재소가 가능하다. 또한 소송요건의 흠결을 이유로 소를 부적법하게 처리하는 소각하 판결과도 구분되는데, 취하는 당사자의 의사에 의한 종료인 반면, 각하는 법원의 판단에 의한 종료이다.

2. 소취하의 요건[민소법 제266조, 제277조]

(1) 당사자에 대한 요건

- 소의 취하는 소송행위이므로 원고에게 소송능력이 있어야 하며, 소송대리인이 취하할 경우에는 소의 취하에 관한 특별수권이 있어야 한다. 피고가 여러 명인 임의적 공동소송의 경우 원고는 그중 1인에 대해서만 소를 취하할 수 있는 것이 원칙이나, 필수적 공동소송의 경우에는 공동소송인 전원이 함께하거나, 전원에게 대하여 하지 않으면 효력이 없다.

(2) 소송물에 대한 요건

- 소의 전체뿐만 아니라 소의 일부에 대해서도 취하가 가능하다. 단, 일부 취하는 소송물의 가분성이 전제되어야 하며, 특정되지 않은 일부 취하는 허용되지 않는다.

(3) 시기

- 소의 취하는 소가 제기된 후부터 판결이 확정될 때까지 언제든지 할 수 있다. 상소심에서도 가능하다. 다만, 항소심에서 소를 취하하면 제1심 판결은 소급하여 효력을 잃게 된다.

(4) 방식

- 소의 취하는 서면으로 하는 것이 원칙이나, 변론기일 또는 변론준비기일에서는 구술로도 할 수 있다. 구술로 취하하는 경우에는 그 내용을 조서에 기재하여야 한다. 소 취하서가 제출된 경우 법원은 이를 상대방에게 송달하여야 한다.

(5) 피고의 동의

- 피고가 본안에 대하여 준비서면을 제출하거나 변론을 한 후에는 피고의 동의를 얻어야 취하의 효력이 발생한다. 이는 피고가 응소하여 승소 판결을 받을 기대를 가지게 된 것을 보호하기 위함이다. 소 취하 통지를 받은 날로부터 2주 이내에 피고가 이의를 제기하지 않으면 동의한 것으로 간주한다.

3. 소취하의 효과

(1) 소송법상 효과

- 소 취하가 유효하면 소송계속은 소급적으로 소멸한다. 처음부터 소가 제기되지 않았던 것과 같은 상태가 되며, 이미 선고된 판결이 있더라도 그 효력은 상실된다. 다만, 소송비용은 원칙적으로 취하한 원고가 부담하게 된다.

(2) 사법상 효과

- 소의 제기로 발생하였던 시효중단의 효과나 법률상 기간 준수의 효과가 소급적으로 소멸한다. 민법 제170조에 의하면 소 취하 후 6개월 이내에 다시 재판상 청구 등을 하지 않으면 시효중단의 효력이 없다.

4. 소취하 간주

- 당사자 쌍방이 변론기일에 불출석하거나 출석하더라도 변론하지 아니한 경우, 1개월 이내에 기일지정신청을 하지 않거나 다시 열린 기일에서도 양쪽이 불출석하면 소를 취하한 것으로 본다. 이를 상불출에 의한 소취하 간주라 하며, 소송 지연을 방지하기 위한 제도이다.

5. 소취하의 효력을 다투는 절차

- 소 취하가 무효이거나 취소 사유가 있다고 주장하는 당사자는 소송종료선언을 구하는 기일지정신청을 할 수 있다. 법원은 기일을 열어 취하의 유효여부를 심리하며, 취하가 유효하다고 판단되면 소송종료선언 판결을 하고, 유효하지 않다고 판단하면 변론을 계속하여 진행한다.

II. 재소금지

1. 서설

(1) 의의

- 민소법 제267조 제2항에 따라 본안에 대한 중국판결이 있는 뒤에 소를 취하한 사람은 같은 소를 제기하지 못한다는 원칙을 의미한다.

(2) 취지

- 법원의 중국판결이 내려졌음에도 불구하고 당사자가 임의로 소를 취하하고 다시 같은 소를 제기하여 법원을 농락하거나 상대방을 괴롭히는 부당한 소송행위를 방지하기 위함이다. 즉, 국가의 재판권 낭비를 막고 판결의 권위를 보호하기 위한 공익적 목적을 가진다.

2. 재소금지의 요건★

(1) 당사자의 동일

- 전소의 원고와 후소의 원고가 동일인이어야 한다. 원고의 포괄승계인도 동일인에 포함된다. 다만, 피고가 달라지는 경우에는 원칙적으로 재소금지가 적용되지 않으나, 소송물의 성질상 피고가 달라도 실질적으로 동일한 분쟁이라면 적용될 수 있다.

(2) 소송물의 동일

- 전소와 후소의 청구취지 및 청구원인이 동일해야 한다. 소송물의 범위가 전소보다 축소된 경우에도 재소금지에 해당할 수 있으나, 소송물이 전혀 별개인 경우에는 적용되지 않는다.

(3) 권리보호이익의 동일

- 후소를 제기할 만한 새로운 정당한 사유가 없어야 한다. 판결 후 사정변경이 생겨 다시 소를 제기할 수밖에 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 재소금지에 저촉되지 않는다는 것이 판례의 태도이다.

(4) 본안에 대한 중국판결 후 소취하

- 제1심 판결이 선고된 후 상소심에서 소를 취하하는 경우가 대표적이다. 판결이 형식적으로 확정되기 전이라도 중국판결이 선고된 상태에서 취하했다면 이 요건을 충족한다.

3. 재소금지의 효과

(1) 소송법상 효과

- 재소금지의 요건에 해당하면 후소는 부적법한 소가 되어 법원은 판결로써 이를 각하하여야 한다. 이는 직권조사사항이며, 피고의 동의 여부와 관계없이 적용된다.

(2) 실체법상 효과

- 재소금지는 소송법상의 제재이므로 원고의 실체법상 권리 자체를 소멸시키는 것은 아니다. 따라서 소송 외에서 그 권리를 행사하거나 상계의 자료로 삼는 것은 가능하다. 다만, 재판을 통해서 그 권리를 실현할 길은 봉쇄된다.

Ⅳ. 결론

- 소의 취하와 재소금지는 민사소송법에서 처분권주의와 소송경제의 조화를 꾀하는 핵심 기제이다. 원고는 소 취하를 통해 언제든지 소송의 구속에서 벗어날 수 있는 자유를 누리지만, 법원의 종국판결이 내려진 후에는 그 자유에 엄격한 책임이 따른다. 재소금지 원칙은 당사자가 국가의 재판 기능을 무의미하게 만드는 행위를 차단함으로써 소송 제도의 존엄성을 유지한다. 당사자는 소 취하 시 발생할 수 있는 시효중단의 실효 및 재소금지의 위험을 충분히 인지하여야 하며, 법원은 취하의 유효성 여부와 재소금지 해당 여부를 엄격히 심사하여 절차적 정의를 실현하여야 한다. 결국 이러한 제도적 장치들은 소송절차의 효율성을 도모하고 당사자 간의 불필요한 분쟁 반복을 방지하여 법적 평화를 조속히 정착시키는 데 기여한다.